

**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC**

SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / Descuido y Negligencia de los deberes funcionales.

Sea lo primero referir, que la labor de sustanciación o instrucción que se le confía en la administración pública, generalmente a aquellos servidores que ostentan la calidad de abogados, exige precisamente un especial cuidado y conocimiento frente al manejo de conceptos jurídicos igualmente calificados, que como en el presente caso no debieron pasar inadvertidos para la procesada, al momento de enfrentarse, por razón de sus deberes funcionales, a la revisión y proyección de un acto administrativo de respuesta, frente a una petición tan puntual como la que fue objeto del presente juicio.

Ciertamente, para una servidora abogada, con la formación y experiencia que rodean a la funcionaria acusada, el hecho de recibir la asignación o el reparto de un expediente, con la finalidad de resolver una solicitud de revocatoria directa, inmediatamente debió generar en la funcionaria la necesidad de conocer y estudiar el origen de la petición, para poder evaluar/o considerar los tiempos o términos procesales. Es precisamente en este punto donde se empieza a advertir el comportamiento negligente o descuidado de la servidora implicada, quien al recibir la asignación o reparto, ante una revisión diligente o cuidadosa, tuvo que advertir que el oficio de remisión de la revocatoria hacía mención expresa y concreta a un segundo radicado, que inmediatamente debió ser ubicado antes de proceder a proyectar la decisión del 4 de diciembre de 2008, que confirmó la sanción de tipo cambiario, correspondiente a la resolución de revocatoria 724. En el mismo sentido, el estudio detenido y prudente del expediente cambiario 0074, que permaneció en poder de la procesada por algo más de tres meses, hubiera permitido encontrar la petición radicada bajo el N° 723. Como bien lo sabe la servidora enjuiciada, quien posee una vasta experiencia en el tema, la proyección de este tipo de decisiones de fondo, exige de los funcionarios sustanciadores, encargados de proyectar el acto administrativo de respuesta, igualmente una revisión exhaustiva de los antecedentes procesales, con la cual necesariamente habría sido manifiesta la existencia del radicado 723, de origen tributario, el cual, con el conocimiento de la procesada, rápidamente debió ser direccionado ante la División Jurídica de Impuestos de Cartagena, evitando así la configuración del silencio administrativo, con una oportuna respuesta.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 48 NUMERAL 35

Dependencia:	Dirección General
Número del Proceso:	1704-01-2012-89
Número y fecha del fallo:	00017 del veintisiete (27) de mayo de dos mil catorce (2014)
Asunto:	Fallo de segunda instancia
Criterio de Selección:	Fallo de primera instancia confirmados.

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-01-2012-89.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el despacho a resolver los recursos de apelación interpuestos por los sujetos procesales (XXX), en su calidad de procesada, y (XXX), en su condición de defensor de confianza de la enjuiciada, contra el fallo sancionatorio proferido en audiencia por el Subdirector Técnico de Investigaciones Disciplinarias, el pasado 2 de diciembre de 2013, dentro del expediente disciplinario 1704-01-2012-89.

COMPETENCIA

La suscrita Directora General de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, es competente para resolver la presente impugnación, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 4173 de 2011, aclarado por el Decreto 4452 de 2011, en atención a las previsiones contenidas en los numerales 12 y 13 del artículo 3° del Decreto 00985 del 14 de mayo de 2012, y al contenido del artículo 171 de la Ley 734 de 2002.

HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES

1.- Los hechos que originaron la presente actuación disciplinaria se derivaron de la Resolución Administrativa 90004, proferida el 27 de abril de 2010 por la Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN. Con base en esta decisión, se declaró el silencio administrativo positivo, respecto a una solicitud de revocatoria directa interpuesta por el contribuyente (XXX), a través de su apoderado especial. Como consecuencia de la anterior determinación, se remitieron copias del expediente administrativo respectivo, el 6 de julio de 2010, ante la Subdirección de Control Disciplinario de la DIAN, para establecer la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios que, con su actuar, pudieron ocasionar la declaratoria del silencio administrativo referido.

2.- Por los hechos relatados en el numeral precedente, la Coordinación Nacional de Investigaciones Especiales de la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN, dependencia que conoció inicialmente del caso, mediante auto datado el 31 de enero de 2011, dispuso la apertura de indagación preliminar, en averiguación de responsables.

3.- Habiéndose decretado y practicado algunas pruebas testimoniales y documentales, tendientes al perfeccionamiento de la indagación preliminar, el funcionario instructor de conocimiento profirió el auto fechado el 22 de junio de 2011, ordenando abrir investigación formal disciplinaria en contra de las servidoras DIAN, (XXX). Las funcionarias investigadas fueron notificadas personalmente de la decisión, los días 5 y 11 de julio de 2011, respectivamente. Ver fls. 140 a 265 del c. o.

4.- Después de practicarse los testimonios de: (XXX); y luego de escucharse en diligencia de versión libre a las investigadas, el funcionario instructor dispuso la prórroga de la investigación por el término de tres meses, mediante decisión calendada el 10 de enero de 2012. En este mismo auto se ordenó la vinculación del servidor (XXX), como investigado.

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-01-2012-89.

Los servidores (XXX) se notificaron personalmente del auto aludido, los días 13 y 27 de febrero de 2012. Ver fls. 337 a 562 del c. o.

5.- El 28 de marzo de 2012, el mismo instructor, dispuso el cierre de la investigación de conformidad con las previsiones legales del artículo 160 A de la Ley 734 de 2002. La decisión se notificó personalmente a los procesados (XXX), el 11 de abril de 2012. Encontrándose en curso el trámite de notificación del auto de cierre a los implicados, el funcionario de conocimiento ordenó, mediante auto del 2 de abril de 2012, la remisión del expediente disciplinario ante esta UAE, por competencia, avocándose el conocimiento del plenario el 3 de diciembre de 2012, por el Subdirector Técnico Disciplinario de la agencia ITRC. Ver fls 564 a 582.

6.- Con fecha 16 de julio de 2013, el funcionario a quo evaluó el mérito de la investigación disciplinaria, cambiando el procedimiento de ordinario a verbal, para lo cual citó a audiencia a la servidora (XXX), llamándola a responder por la falta disciplinaria prevista en el numeral 35 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. En la misma decisión se ordenó la terminación del procedimiento y el archivo definitivo de la actuación, en favor de los procesados (XXX), quienes se notificaron por Estado del 31 de julio de 2013 y personalmente el 14 de agosto del mismo año. Finalmente, el auto de citación a audiencia se notificó por edicto el 21 de agosto de 2013. Ver fls. 586 a 616 del c.o.

7.- Llegado el 14 de noviembre de 2013, en la ciudad de Cartagena, se dio inicio a la Audiencia pública, con la presencia de la procesada (XXX), quien otorgó poder en el acto al profesional del derecho (XXX), para ejercer su defensa técnica. Ante una solicitud de terminación del proceso, por posible prescripción, realizada por el defensor de confianza, la audiencia fue suspendida, para continuarla el 20 de noviembre de 2013, en Bogotá D. C. En esta nueva oportunidad, el director de la Audiencia resolvió negativamente la solicitud de declaratoria de prescripción de la acción. Acto seguido, el abogado defensor presentó alegatos de conclusión.

8.- Después de un receso, la audiencia fue reanudada el 2 de diciembre de 2013, escuchándose en esta ocasión a la procesada, en ampliación de su versión. En desarrollo de este medio defensivo, la investigada solicitó la práctica de pruebas testimoniales y aportó algunas pruebas documentales. Las primeras fueron rechazadas por extemporáneas, mientras que las segundas se admitieron para ser evaluadas al momento de proferir el fallo. Notificada la anterior decisión en estrados a los sujetos procesales presentes, se consideró concluida la etapa probatoria del juicio y se procedió a dar lectura al fallo de primera instancia, a través del cual se declaró a la procesada responsable de la conducta objeto de acusación, imponiéndole como sanción suspensión del cargo por un mes e inhabilidad especial por el mismo término.

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-01-2012-89.

9.- En fallo de primera instancia fue apelado por los sujetos procesales presentes en la audiencia, siendo sustentado por el defensor técnico, mediante escrito allegado el 4 de diciembre de 2013, y por la procesada, mediante memorial recibido vía e-mail, el 3 del mismo mes y año. Ver fls. 665 a 700 del c. o.

10.- Las diligencias disciplinarias fueron recibidas en este despacho de segundo grado el 2 de diciembre de 2013, para desatar la alzada. Ver fl. 730 del c. o. Encontrándose en curso el trámite de la apelación, fue recibido y anexado al plenario, procedente de la secretaría técnica, el correspondiente escrito de sustentación de la apelación, firmado por el abogado (XXX), (según constancia del 28 de enero de 2014, visible a folios 731 y 746 del c. o.

11.- Mediante auto calendado el 28 de enero de 2014, este despacho ad quem ordenó dar aplicación al inciso séptimo del artículo 180 del C. D. U. corriendo traslado a los sujetos procesales, para presentar alegatos de conclusión en el trámite de segunda instancia. La decisión en comento fue notificada personalmente al profesional (XXX) el 4 de febrero de 2014, quien solicitó, mediante escrito recibido el 6 del mismo mes y año, tener como alegatos de segundo grado, el mismo escrito de sustentación de la apelación, presentado en la primera instancia.

Por otra parte la procesada (XXX) fue notificada personalmente del auto de traslado, en segunda instancia, el 21 de febrero de 2014; recibéndose en este despacho su escrito de alegaciones de segundo grado, el 5 de marzo de 2014. Ver fls. 747 a 778 del c. o.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN IMPUGNADA

El fallo de primera instancia inició por hacer concreción sobre la identidad de la servidora investigada y el cargo desempeñado por ésta, para la época en que se presentaron los hechos objeto de investigación. Igualmente se hizo referencia a la normatividad legal que atribuyó competencia a esta entidad, para conocer y fallar conductas de relevancia disciplinaria. Seguidamente, fueron resumidos los hechos y las actuaciones procesales desarrolladas en el presente juicio, para concluir haciendo una síntesis del cargo por el cual debió responder la procesada.

Las consideraciones subsiguientes se centraron en analizar las pruebas documentales y testimoniales allegadas, a través de las cuales se reconstruyó el trámite de la petición de revocatoria directa que motivó la declaratoria de silencio administrativo positivo, originaria de esta actuación.

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-01-2012-89.

En un título posterior, el a quo despachó desfavorablemente los argumentos de defensa de la investigada y su apoderado. En este acápite sustentó nuevamente su posición negativa, frente a la pretensión de prescripción de la acción disciplinaria, alegada por el defensor técnico.

Los anteriores planteamientos y análisis probatorios, permitieron al fallador de instancia hacer un estudio de los requisitos probatorios necesarios para proferir un fallo sancionatorio, consagrados en el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, en armonía con los requisitos de legalidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, previstos en los artículos 4, 5 6 y 13 de la misma norma en cita. En lo que respecta a la tipicidad de la conducta, reiteró el operador jurídico de primer grado, que el comportamiento de la procesada encontró adecuación dentro de la descripción típica disciplinaria, abstracta, prevista en el numeral 35 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Agregó el fallador que la conducta la enjuiciada afectó sustancialmente la función pública, cumpliéndose el requisito de ilicitud sustancial. Finalmente, en lo que atañe al elemento subjetivo de la imputación, se concluyó probado que la procesada cometió la falta gravísima, tantas veces mencionada, a título de culpa grave, por haber obrado en forma omisiva y negligente en el cumplimiento de sus deberes funcionales. Con inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona imprime a sus actuaciones.

Con fundamento en las condiciones especiales de la conducta objeto de reproche y atendiendo a los lineamientos legales consagrados en el numeral 2 del artículo 44 del C. D. U., en armonía con el artículo 46 de la misma norma, consideró el a quo que la sanción a imponer en el caso concreto no sería otra que la de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial, por encontrarse ante una falta gravísima culposa. Para determinar el monto de la suspensión y de la inhabilidad especial, el fallador de instancia partió del mínimo posible, evaluando en favor de la procesada la ausencia de antecedentes disciplinarios; haber desempeñado un cargo que no pertenecía a los niveles directivos; la no afectación de derechos fundamentales y; por último, su intachable desempeño profesional en la DIAN, hasta el momento en que se presentaron los hechos objeto de investigación. Como criterio en contra de la enjuiciada, se consideró su actuar negligente o culposa, en contraposición a su experiencia y trayectoria.

Con estas consideraciones, el funcionario de primer grado, al declarar la responsabilidad disciplinaria de la procesada, resolvió imponer como sanción disciplinaria una Suspensión en el ejercicio del cargo, por el término de UN mes, e inhabilidad especial por el mismo término.

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

Dentro de la oportunidad procesal pertinente, esto es, dentro del término de dos (2) días conferido por el director de la audiencia, a partir del momento en que se realizó la lectura del fallo, los sujetos procesales presentaron sus correspondientes memoriales de apelación, contra la decisión de primera instancia, dentro de los cuales se pueden sintetizar los siguientes argumentos sustento de su impugnación:

1.- La procesada (XXX), inició afirmando que interpuso su recurso contra el fallo apelado "...por Violación al Debido Proceso ay al Derecho de Defensa a la Falsa Motivación del acto recurrido..."

1.1.- En desarrollo de sus argumentos defensivos, presentó la impugnante un primer título que denominó: "...ERRORES FORMALES Y DE FONDO PRESENTADOS EN EL FALLO

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-01-2012-89.

DE LA PRIMERA INSTANCIA: ...". En este acápite planteó la recurrente una idea inicial al afirmar reiterativamente, refiriéndose a la solicitud de revocatoria directa: "...NO LO VI, NO ME FUE REPARTIDO por quienes en su momento tenían la función de hacer el reparto de los expedientes. ...". A partir de esta idea, señaló la procesada que la responsabilidad del hecho imputado obedeció "...más a un problema operacional e institucional cuya causa YO no generé. ...". Con este planteamiento, pasó la recurrente a atribuir la responsabilidad del hecho a otros funcionarios tales como: Myriam Stella Díaz Corredor, Jefe del GIT de notificaciones y correspondencia de la administración especial de personas jurídicas de Bogotá; Luz Stella Hernández Alfaro, secretaria de la División Jurídica Aduanera; Nagith Alberto Orgullosa Rada, Jefe de la División Jurídica; Paola Rozo, Administradora del sistema de control de procesos en la División Jurídica. Según la recurrente, estos servidores tuvieron la posibilidad de advertir que se estaban tramitando dos solicitudes de revocatoria, conjuntamente, por lo que debieron imprimir los correctivos del caso, para evitar la confusión posteriormente presentada. Agregó la procesada, reiterando sus alegaciones finales, que existieron dieciséis "...FILTROS DE CONTROL simultáneos y posteriores al reparto del expediente IX03030074, los cuales pasaron inadvertidos frente al trámite de las dos solicitudes de revocatoria directa.

En una idea final, criticó expresamente la impugnante la valoración efectuada por el a quo, con relación al oficio 1-48-236-00170 fechado el 17 de febrero de 2011, por el funcionario Javier Bermejo Arrieta, Jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena. En su concepto, el análisis de dicho documento se constituye en una falsa motivación, una violación al debido proceso y al derecho de defensa, por haberse realizado una valoración "...sesgada, parcial y malintencionada ...".

1.2.- La impugnante agrupó algunas ideas bajo el título: "...FALSA MOTIVACIÓN Y VIOLACIÓN OSTENSIBLE a la garantía constitucional AL DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA,...". Para dar comienzo a estas argumentaciones, expresó la procesada que la responsabilidad que le fue endilgada en primera instancia, se fundó en una presunta confesión, valorada ilegalmente por el fallador a quo, sin el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 280 del C. de P. P. (Ley 600 de 2000). A continuación, reiteró la recurrente la existencia de un presunto error o cadena de errores que, al ser atribuibles a otros funcionarios, justifican su actuar y demuestran, según su concepto: Que por una parte, no vio el escrito de revocatoria directa motivó esta actuación, y, por otra, que pese a existir 16 filtros de control, previos, simultáneos y posteriores a la entrega del expediente, ninguno advirtió la existencia del citado memorial, perteneciente a otro tipo de investigación.

Señaló la recurrente que el fallador de instancia no tuvo en cuenta los documentos allegados por ella en su diligencia de ampliación de versión, con los cuales pretendió justificar su actuar, demostrando una carga laboral excesiva, durante el tiempo de ocurrencia de los hechos.

Finalmente, realizó la apelante una crítica directa a la compulsación de copias, con fines de adelantar una posible acción fiscal en su contra, ordenada por el fallador a quo. Al respecto, argumentó que nunca tuvo a su cargo gestión fiscal y que no se dan los requisitos legales previstos en el artículo 5º de la Ley 610 de 2000, necesarios para declararla responsable fiscalmente, razón suficiente para dar aplicación al artículo 47 de la misma norma citada.

Con base en estas consideraciones, solicitó la impugnante Revocar el fallo sancionatorio proferido en su contra por la primera instancia y, en su lugar, "...se proceda con el ARCHIVO DEFINITIVO DE LA INVESTIGACIÓN por las violaciones flagrantes contenidas en la misma al DEBIDO PROCESO DERECHO DE DEFENSA AL PRINCIPIO A LA IGUALDAD. ...".

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-01-2012-89.

2.- El abogado defensor, (XXX), después de hacer un recuento breve del acontecer procesal, expresó su inconformidad con el fallo apelado, señalando enfáticamente que: la actuación equívoca que dio lugar al presente disciplinario se originó en la remisión ejecutada por la funcionaria Myriam Stella Díaz Corredor, Jefe del GIT Notificaciones y Correspondencia de la Administración Especial de Personas Jurídicas, a través del oficio No. 030-023-215-278 de julio 17 de 2008, con el cual se enviaron ante la Aduana de Cartagena, en forma simultánea, dos solicitudes de revocatoria directa, una, contra una sanción cambiaria y la otra, contra una sanción tributaria. Según el apelante, esta actuación, la cual calificó como un “grave error” “...arrastró a todos los funcionarios de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena que tuvieron que ver con el trámite de la revocatoria directa presentada por el apoderado de la empresa (XXX). ...”. Con esta afirmación, el apelante pasó a hacer un recuento de los servidores que, en su concepto, efectuaron revisiones previas a la solicitud de revocatoria directa, constituyéndose, según sus manifestaciones defensivas, en “...FILTROS DE CONTROL...” previos y posteriores a la actuación de su defendida.

A continuación, evocó el impugnante las pruebas documentales y testimoniales que, según su dicho, evidencian una posible confusión generada en la similitud de las dos peticiones de revocatoria presentadas, anunciando este hecho como posible justificación del proceder de su poderdante.

Con base en estos razonamientos concluyó el recurrente lo siguiente: “...En este panorama que se deriva de las pruebas allegadas al disciplinario, se tiene entonces que la presunta negligencia con culpa grave sería predicable no sólo de la sustanciadora (XXX) sino, así mismo, de todos los demás funcionarios que tuvieron que ver con el expediente, conocieron la solicitud de revocatoria directa en materia cambiaria y no se percataron que anexa se hallaba la solicitud de revocatoria directa en materia tributaria. ... En ese contexto probatorio los efectos de la actuación culposa tendrían que implicar a todos los funcionarios con la respectiva modulación de acuerdo con la razón por la cual tuvieron acceso y relación con el expediente, y no solo a la sustanciadora quien a pesar de ser quien proyectó el acto administrativo que resolvió la solicitud de revocatoria directa en materia cambiaria, fue como todos los otros funcionarios víctima del error originado por la forma unificada en que desde el GIT de Notificaciones y Correspondencia de la Administración Especial de Personas Jurídicas se envió a la Administración Especial de Cartagena, las solicitudes de revocatoria directa presentadas por el apoderado de la empresa (XXX). ...”.

Para el togado apelante, la valoración probatoria realizada por la primera instancia, resultó sesgada y violatoria del debido proceso. Adicionalmente, señaló el recurrente que todos los funcionarios relacionados con la solicitud de revocatoria directa, actuaron conforme al principio de confianza legítima, que según su dicho, se concreta en el deber de cuidado en todos aquellos casos en que la eventual concreción de una irregular actuación presuntamente violatoria de la ley, está condicionada por la actuación de un tercero.

En un numeral a parte del escrito de sustentación, arguyó el apelante que el funcionario instructor dirigió el proceso hacia la nulidad, por violación del debido proceso y del derecho de defensa de conformidad con las previsiones legales consagradas en los numerales 2 y 3 del artículo 143 de la Ley 734 de 2002.

Como sustento de su petición de nulidad, señaló el recurrente: “...En la primera fase de la audiencia al proponer la defensa la prescripción de la acción disciplinaria, el funcionario instructor seguidamente corrió traslado para alegar de conclusión, fracturando la estructura del proceso verbal porque si a su juicio no estaba configurada la prescripción debió entonces

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-01-2012-89.

surtir la continuidad de la audiencia de acuerdo con la secuencia regulada en el artículo 177 de la LEY 734 de 2002, modificado por el artículo 58 de la LEY 1474 de 2011, esto es oír la versión libre y verificar si solicitaba o no pruebas la disciplinada, pero no brincar de una a los alegatos de conclusión, pues lo que así hizo fue subvertir el trámite del proceso verbal. ...”Continuando con su argumentación, manifestó el defensor impugnante: “...En la reanudación de la audiencia la disciplinada solicitó la práctica de pruebas respecto de las cuales el funcionario instructor omitió pronunciarse en el sentido de si las ordenaba o las negaba, cuando su deber como garante del Derecho de Defensa y del Debido Proceso, era el de pronunciarse en uno u otro sentido y en el evento de haberlas negado hacerlo sustentadamente y observar la regulación del artículo 180 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011.

En el penúltimo párrafo del recurso, solicitó el apelante a esta instancia “...verificar la recepción del testimonio de la doctora ALBA LÍA MARTÍNEZ JAIMES, y de todos y cada uno de los funcionarios que la doctora BERTA solicitó en la versión escrita que rindió a este despacho. ...”.

Fueron estos los planteamientos que llevaron al profesional de la defensa técnica a solicitar LA revocatoria total del fallo impugnado, con el argumento conclusivo referente a que la procesada no incurrió en la falta objeto de sanción, ya que nunca conoció ni tuvo expresamente a su alcance la solicitud de revocatoria directa en el expediente tributario No. II20022006551.

ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA.

Esta oportunidad procesal fue inutilizada por el defensor técnico de la procesada, quien alegando razones de “economía personal”, se remitió al contenido del recurso interpuesto y sustentado ante la primera instancia.

Por su parte la servidora implicada presentó un extenso escrito, en el cual reiteró los argumentos defensivos que presentó como alegatos de conclusión, ante la primera instancia; así como las razones de sustentación de la impugnación contra el fallo de primer grado. Insistió la procesada en hacer notar los errores formales y de fondo en la expedición del fallo apelado.

Afirmó nuevamente que nunca vio ni le fue repartido el recurso extraordinario de revocatoria directa, que generó la declaratoria de silencio administrativo. Alegó, una vez más, sobre la existencia de posibles filtros de control que pasaron inadvertidos dentro del trámite del recurso extraordinario, con lo cual pretende justificar su actuación y demostrar la responsabilidad de los hechos en cabeza de otros servidores, tanto de la DIAN – Bogotá, como de la DIAN - Cartagena.

En el mismo sentido, volvió a expresar su inconformidad con la valoración probatoria realizada por el a quo, calificando la misma como una “falsa motivación”, violatoria de los principios de igualdad y presunción de inocencia. En este punto, resaltó la encartada que fue valorada en su contra una posible confesión, recaudada irregularmente.

Una vez más reclamó la apelante en su favor la aplicación del principio de confianza legítima.

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-01-2012-89.

En un acápite titulado “Responsabilidad Institucional”, la procesada reclamó nuevamente la valoración de su carga de trabajo, relacionando todas las actividades, recursos y contingencias relativas a su desempeño funcional.

Por último, en su escrito de alegaciones de segunda instancia, la enjuiciada hizo reiteración a la solicitud de pruebas realizada en desarrollo de la audiencia de fallo, ante la primera instancia.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Antes de dar inicio a estas consideraciones, es importante recordar a los impugnantes que de conformidad con la previsión legal consagrada en el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, “...El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar, únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación. ...”.

Pese a la variedad de planteamientos defensivos expuestos por los sujetos procesales y a pesar de que cada uno de ellos tendrá una respuesta de segundo grado, considera este despacho ad quem necesario empezar por hacer un pronunciamiento concreto sobre el cumplimiento del requisito probatorio mínimo exigido en el artículo 142 de la Ley disciplinaria, para proferir o no un fallo sancionatorio. Lo anterior teniendo en cuenta que la crítica central de los impugnantes está basada en la posible valoración probatoria irregular del a quo, la cual es calificada como “sesgada”, “parcial” y “malintencionada”.

Debe empezar por resaltar este despacho que la simple manifestación de inconformidad o desacuerdo de los sujetos procesales, frente a la valoración probatoria del operador jurídico de instancia, no es motivo suficiente para tildarla de “**parcial**”, “**sesgada**” y “**mal intencionada**”. Por tanto, este despacho expresa su desacuerdo con este tipo de argumentación, que en ningún momento constituye una adecuada forma de ejercer el derecho de contradicción y, por el contrario, desdice de la lealtad y respeto con que los profesionales del derecho deben atender sus asuntos, ya sea en desarrollo de una defensa material o de una defensa técnica, dentro de una actuación procesal.

Sin lugar a dudas, una falta disciplinaria como la que nos convocó en este juicio verbal disciplinario, parte de unos requisitos probatorios muy claros y sencillos. En primer lugar demostrar la ocurrencia de un fenómeno jurídico administrativo concreto, como lo es la ocurrencia del silencio administrativo positivo. En segundo lugar, partiendo de ese hecho particular, establecer cuál fue la causa que dio lugar a tal declaratoria. Para este efecto, el funcionario de conocimiento acudió a una abundante prueba documental y testimonial, que fue valorada de la siguiente manera:

La realidad probada del silencio administrativo positivo no revistió mayor dificultad. Documentalmente se estableció que la ocurrencia de ese fenómeno jurídico – administrativo, fue declarada el 27 de abril de 2010, mediante Resolución 90004, expedida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN. Las consideraciones fundamento de dicha decisión, demuestran claramente, que transcurrió más de un año, desde el **14 de julio de 2008**, fecha en que el abogado (XXX), apoderado especial de la compañía (XXX), presentó ante la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, la correspondiente solicitud de revocatoria, de la resolución sancionatoria No. 0033 del 18 de julio de 2006, proferida por la División de Liquidación Tributaria de la Administración Local de Impuestos de Cartagena, hoy Dirección Seccional

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-01-2012-89.

de Impuestos de Cartagena. Dicha petición de revocatoria directa fue radicada bajo el número 723.

Ahora bien, al momento de indagar sobre las causas que dieron lugar a dicha declaratoria de silencio administrativo positivo, el instructor disciplinario acudió nuevamente, tanto al expediente administrativo respectivo, como a las restantes pruebas documentales que fueron decretadas y recaudadas a lo largo del juicio.

Haciendo seguimiento al trámite que se le dio a la solicitud de revocatoria directa **723 del 14 de julio de 2008**, se pudo establecer que la misma fue direccionada o remitida por la servidora MYRIAM STELLA DÍAZ CORREDOR, en su condición de Jefe del GIT de Notificaciones y Correspondencia de la Administración Especial de Personas Jurídicas, ante la División Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, mediante oficio 215-278 del **17 de julio de 2008**. Aparece probado igualmente que con este mismo oficio se remitió, de manera simultánea, otra solicitud de Revocatoria Directa, también presentada por el mismo profesional apoderado de (XXX), con radicado 724, esta vez contra la resolución sancionatoria 001653 del 7 de julio de 2006, proferida por la Administración Especial de Aduanas de Cartagena.

Resulta entonces claro dentro del presente proceso, tanto para el operador jurídico de instancia como para este despacho ad quem, que las dos solicitudes de revocatoria directa, radicadas bajo los números 723 y 724 del 14 de julio de 2003, fueron asignadas o repartidas para su estudio y decisión a la abogada implicada, quien las recibió junto con el oficio remisorio, anexo al expediente 0074, el **8 de agosto de 2008**. Así lo corroboró el propio servidor Javier Bermejo Arrieta, Jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, en informe rendido ante el funcionario instructor de instancia, basado en el reporte de la base de datos de esa División y en la planilla de reparto de expedientes. Adicionalmente, esta misma aseveración fue ratificada por el mismo servidor en su declaración juramentada.

Veamos entonces, qué trámite realizó la procesada con las dos solicitudes de revocatoria, remitidas mediante el oficio 030-023-215-278- del 17 de julio de 2008., repartido o asignado con el expediente 0074. El 8 de agosto de 2008:

Frente al radicado 724, contentivo de una solicitud de revocatoria directa, de una resolución de tipo Cambiario, la servidora encartada proyectó la correspondiente decisión de confirmación de la sanción, para la firma del Director Seccional de Aduanas de Cartagena, señor Humberto Angulo Montero, quien le impartió aprobación al suscribir la Resolución 200800257 del 4 de diciembre de 2008.

A su turno el radicado 723, referente a la solicitud de revocatoria de una sanción de carácter tributario, permaneció sin trámite o decisión, hasta el mes de octubre de 2009, cuando el propio apoderado del contribuyente (XXX), requirió a la administración, solicitando la declaratoria del silencio administrativo. Esta advertencia o alerta puso en movimiento a los funcionarios de la División Jurídica de Impuestos de Cartagena y de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, quienes se dieron a la tarea de ubicar el citado documento. Hecho que finalmente concluyó en la División de Gestión Jurídica de Aduanas de Cartagena, despacho que anunció, el **5 de marzo de 2010**, haber encontrado la solicitud de revocatoria aludida, al revisar el expediente 010139200320030074, razón por la cual, mediante auto de la misma fecha, se ordenó el desglose del radicado y su remisión ante la División de Gestión Jurídica Tributaria de la misma ciudad; donde finalmente se remitió la documentación el **9 de marzo de 2010**, ante la Subdirección de Gestión de Recursos Tributarios de la Dirección de Gestión Jurídica en el nivel central; donde finalmente se expidió la Resolución 900004

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-01-2012-89.

del **27 de abril de 2010**, a cargo de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica, declarando el silencio administrativo positivo.

Este recuento de la trayectoria que siguió la solicitud de revocatoria directa No. 723, desde el momento de su radicación hasta cuando tuvo lugar la declaratoria del silencio administrativo, permite a esta instancia demostrar a los sujetos procesales impugnantes, el conocimiento y claridad que se tiene sobre el acontecer fáctico. Adicionalmente, se conforma la premisa inicial que desvirtúa totalmente los argumentos defensivos de los apelantes, frente a los temas del presunto error, como posible causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria, o la idea de haber actuado bajo el principio de la confianza legítima.

Con relación al primer argumento, en el que la procesada y su defensa técnica pretenden obtener la exoneración de responsabilidad, atribuyendo el hecho del silencio administrativo a un presunto error ajeno, o como ellos lo llaman, a una “cadena de errores”, que impidieron a la servidora acusada, ver la solicitud de revocatoria N° 723 y darle el trámite correspondiente, encuentra este despacho acertada la posición del a quo, la cual se avala y amplía en los siguientes términos:

Sea lo primero referir, que la labor de sustanciación o instrucción que se le confía en la administración pública, generalmente a aquellos servidores que ostentan la calidad de abogados, exige precisamente un especial cuidado y conocimiento frente al manejo de conceptos jurídicos igualmente calificados, que como en el presente caso no debieron pasar inadvertidos para la procesada, al momento de enfrentarse, por razón de sus deberes funcionales, a la revisión y proyección de un acto administrativo de respuesta, frente a una petición tan puntual como la que fue objeto del presente juicio.

Ciertamente, para una servidora abogada, con la formación y experiencia que rodean a la funcionaria acusada, el hecho de recibir la asignación o el reparto de un expediente, con la finalidad de resolver una solicitud de revocatoria directa, inmediatamente debió generar en la funcionaria la necesidad de conocer y estudiar el origen de la petición, para poder evaluar/o considerar los tiempos o términos procesales. Es precisamente en este punto donde se empieza a advertir el comportamiento negligente o descuidado de la servidora implicada, quien al recibir la asignación o reparto, ante una revisión diligente o cuidadosa, tuvo que advertir que el oficio de remisión de la revocatoria hacía mención expresa y concreta a un segundo radicado, que inmediatamente debió ser ubicado antes de proceder a proyectar la decisión del 4 de diciembre de 2008, que confirmó la sanción de tipo cambiario, correspondiente a la resolución de revocatoria 724. En el mismo sentido, el estudio detenido y prudente del expediente cambiario 0074, que permaneció en poder de la procesada por algo más de tres meses, hubiera permitido encontrar la petición radicada bajo el N° 723. Como bien lo sabe la servidora enjuiciada, quien posee una vasta experiencia en el tema, la proyección de este tipo de decisiones de fondo, exige de los funcionarios sustanciadores, encargados de proyectar el acto administrativo de respuesta, igualmente una revisión exhaustiva de los antecedentes procesales, con la cual necesariamente habría sido manifiesta la existencia del radicado 723, de origen tributario, el cual, con el conocimiento de la procesada, rápidamente debió ser direccionado ante la División Jurídica de Impuestos de Cartagena, evitando así la configuración del silencio administrativo, con una oportuna respuesta.

En este punto del razonamiento, debe responderse a la procesada que no puede ser de recibo su afirmación, cuando aseguró que resultaba difícil, identificar las dos peticiones, por haber sido presentadas por el mismo interesado; quien las elaboró con estilos gráficos idénticos; con estructuras de texto similares; y con identidad de fechas y de intervinientes o interesados. En primer lugar, estas presuntas similitudes de las dos peticiones de

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-01-2012-89.

revocatoria, además de ser lógicas, por responder a la actuación de un mismo contribuyente, quien accionó a través de su único apoderado especial, no son razón suficiente para generar ningún tipo de confusión en un servidor experto y cuidadoso, que conoce con suficiencia la diferencia sustancial entre el tema cambiario y tributario. Adicionalmente, esta misma aseveración, permite deducir que la implicada si tuvo a su vista la solicitud 723, al momento de proyectar la decisión de la petición 724, pero que fue posiblemente por descuido, al considerarla como una copia idéntica, que no le dio el trámite oportuno.

Contrario a lo manifestado por los sujetos procesales, el único error que advierte esta instancia, no fué ajeno a la procesada y, por lo tanto no justifica su actuar; pues se presentó precisamente en el momento en que ella debió realizar la labor de sustanciación o revisión del expediente que le fue asignado o repartido, previamente a la proyección del acto administrativo definitivo, que resolvió la solicitud de revocatoria.

Desarrollando y acogiendo la tesis del fallador de primer grado, es cierto que todos y cada uno de los servidores o funcionarios que tuvieron en su poder las peticiones de revocatoria directa N°s 723 y 724, con anterioridad a la procesada, simplemente ejecutaron actividades secretariales o de trámite, tendientes a direccionar o dar curso a las peticiones revocatorias, hacia la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Cartagena. Sin embargo, para la realización de estas labores, que como lo hemos dicho son de simple trámite, no requerían los citados funcionarios conocimientos específicos ni estudios detallados del expediente disciplinario. Por esto, considera este despacho válida la conclusión del fallador a quo, cuando aseguró que únicamente la gestión cuidadosa y efectivamente realizada por la servidora acusada, en sus tareas de revisión y estudio del proceso cambiario, hubiera podido evitar la consecuencia gravosa del silencio administrativo positivo, al advertir, dentro de su labor de sustanciación, la existencia de la segunda solicitud de revocatoria, imprimiendo los correctivos del caso. Lo anterior ciertamente habría evitado que el trámite procesal permaneciera inactivo desde el 8 de agosto de 2008 hasta el 5 de marzo de 2010.

Estos mismos argumentos permiten al despacho ad quem rechazar los presuntos dieciséis (16) controles que mencionan los impugnantes, atribuyendo a otros funcionarios la posible responsabilidad en el hecho, con el argumento de haber generado una supuesta “cadena de errores”. Debe resaltarse que ninguno de los servidores previos al actuar de la servidora acusada ejercía verdadero control sobre su función de revisión y proyección del acto administrativo respuesta a la solicitud de revocatoria.

Concluyendo, si existió error, el mismo solo es atribuible a la negligencia o descuido de la procesada, a quien se le recuerda que nunca se le formuló el cargo por realizar la conducta de manera dolosa o intencional, sino por haber actuado culposamente. Tampoco puede atribuirse responsabilidad a los restantes funcionarios de la seccional, como lo pretenden los sujetos apelantes, pues debe reiterarse que la única servidora que tuvo bajo su poder o control funcional la sustanciación y proyección del caso subjudice, fue la procesada.

Complementando el análisis o valoración probatoria del fallador de instancia, nótese que pese a que algunos de los declarantes, como el servidor (XXX), pretendieron respaldar el dicho de su compañera, aquí procesada, al referir una presunta confusión o error involuntario, que hizo difícil establecer la existencia de las dos solicitudes de revocatoria, ese planteamiento, como se ha venido motivando hasta el momento, pierde toda prosperidad y validez, ante el ejercicio descuidado y negligente de los deberes funcionales de la procesada, situación que en ningún momento constituye vulneración al principio de igualdad procesal de la enjuiciada, pues simplemente obedece a un ejercicio de valoración probatoria, independiente y autónomo del fallador a quo, el cual se confirma totalmente en desarrollo de esta alzada.

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-01-2012-89.

Con relación al tema del error, como causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria, considera oportuno este despacho hacer referencia a algunos lineamientos doctrinales, sentados por el máximo ente de control disciplinario externo, sobre la aplicación de esta causal, consagrada en el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002:

“...Contrario de lo considerado por la dogmática penal que destaca varias clases de error; el de tipo, el de prohibición, error directo, error indirecto, de hecho, de derecho, vencible o invencible, en materia disciplinaria se ha avanzado hacia la creación de una teoría propia del error, en miras a diferenciar la estructura de la falta disciplinaria de la del delito; encontrando hasta ahora, que resulta más adecuado para el derecho disciplinario acudir a la antigua terminología que distinguía entre el error de hecho y el error de derecho.

El error en materia disciplinaria, atañe directamente a la culpabilidad y se presenta cuando hay discordancia entre la conciencia del autor y la realidad; error que puede ser vencible o invencible, dependiendo de si el autor hubiera podido salir de él aplicando razonabilidad o si a pesar de tener la diligencia debida, no hubiese podido salir del error.

De ahí, que, si el error es invencible, obviamente se excluye la posibilidad de reproche disciplinario; pero si a contrario sensu, es vencible, el autor debe responder por la comisión de la falta. ...”. (Procuraduría Prov. Pto Berrio, IUS 2010-397760, 9 de marzo de 2012).

Aplicando estos lineamientos al caso que nos ocupa, es indudable que el presunto error que los sujetos procesales pretenden argüir en su impugnación, no puede ser calificado como invencible, y en esto se fundamenta precisamente la razón central de la acusación, pues lo que se reprocha a la disciplinada es su descuido o negligencia al momento de realizar su labor de estudio y sustanciación del expediente administrativo, donde tuvo el tiempo y la oportunidad de encontrar el radicado 723 e imprimirle el direccionamiento y corrección, que como ya lo hemos afirmado anteriormente, hubiera evitado la declaratoria del silencio administrativo positivo.

Con invocación del principio constitucional de confianza legítima, pretenden los impugnantes justificar el comportamiento de la procesada, afirmando que desplegó su actuación confiada en el legal proceder de los servidores que, con anterioridad, recibieron, tramitaron y direccionaron la solicitud de revocatoria directa sobre la cual, posteriormente, operó la declaratoria del silencio administrativo positivo.

Esta posición defensiva de los sujetos procesales, tampoco está llamada a prosperar, pues siendo contestes con las motivaciones del fallador de instancia y con los razonamientos de segundo grado, hasta el momento desarrollados, es necesario reiterar que el punto central del reproche disciplinario está enfocado en el ejercicio irregular, por negligencia y descuido, con que la disciplinada asumió su labor de estudio y sustanciación de un expediente administrativo que le fue asignado el 8 de agosto de 2008. En consecuencia, no existe ninguna razón de causalidad, que permita vincular el proceder de la enjuiciada, con las labores de simple trámite que precedentemente pudieron imprimir servidores secretariales. Es más, finalizando esta idea, debe señalarse que era precisamente la servidora enjuiciada quien debió ejercer control posterior sobre el trámite de la petición de revocatoria, situación que al no presentarse, generó la aplicación del silencio administrativo positivo, tantas veces mencionado.

Veamos, transcribiendo algunas breves líneas, cuál es la comprensión y alcance doctrinal y jurisprudencial que existe sobre el principio de la confianza legítima:

“...Sobre este particular merece la pena anotar que el ordenamiento jurídico protege la confianza de los destinatarios de normas y de las decisiones en la permanencia de su

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-01-2012-89.

aplicación, basados en razones objetivas como : (i) Su vigencia por un largo periodo, (ii) No haber sido modificadas, su aplicación obligatoria y (iii) la solidez de sus determinaciones en el sentido de acomodarse de buena fe a lo que ellas prescriben.es dable manifestar que este no solo es aplicable a los administrados, respecto a la actuación de las autoridades públicas, sino también en la relación con los diferentes órganos y entes del poder público, lo que conduce a concluir que es también un deber de los jueces al emitir sus decisiones judiciales actuar respetando este principio constitucional. ... **“El derecho de acceso a la administración de justicia implica la garantía de la confianza legítima en la actividad del Estado como administrador de justicia.** Esta confianza no se garantiza con la sola publicidad del texto de la ley, ni se agota en la simple adscripción nominal del principio de legalidad. Comprende además la protección a las expectativas legítimas de las personas de que la interpretación y aplicación de la ley por parte de los jueces va a ser razonable, consistente y uniforme. “.. (Corte Constitucional Sentencia C-836 del 9 de agosto de 2001, Mp. Rodrigo Escobar Gil.).

Recogiendo los anteriores planteamientos y como respuesta a la procesada, se desdibuja por completo la posible “Falsa Motivación” que mencionó en su escrito de apelación, cuando aseguró que el fallador de primer grado valoró en su contra una posible confesión, obtenida sin el cumplimiento de los requisitos legales. La lectura cuidadosa de la decisión de instancia no permite concluir que haya existido tal valoración, pues como se ha venido exponiendo, fueron pruebas documentales y testimoniales las que llevaron al funcionario a quo a encontrar probado, en grado de certeza, el comportamiento objeto de reproche disciplinario.

De la misma manera, en lo que respecta a la presunta ausencia de pronunciamiento sobre la excesiva carga laboral de la procesada, encontró este despacho que el funcionario a quo si efectuó una valoración al respecto, la cual, pese a no ser aceptada por la impugnante, no significa que la misma no haya sido realizada teniendo como soporte los limitados documentos visibles en el anexo 6 del diligenciamiento, donde la servidora acusada, se limitó a hacer una referencia cuantitativa de 146 expedientes de vía gubernativa, **carente del más mínimo respaldo probatorio real.** Al respecto señaló el operador jurídico de instancia: “...Entonces, el haber manipulado las solicitudes de revocatoria directa y de tener una carga laboral relativamente manejable, pues era menor a la carga laboral de los demás funcionarios de dicha área si se hace un ejercicio de comparación, son circunstancias que permitían que la citada pudiera haber realizado con mayor cuidado su labor y así advertir que se trataban de dos solicitudes de revocatoria diferentes y enviarla al competente. ...”.

La anterior argumentación del fallador de primer grado es lógica y corresponde a los hechos que fueron efectivamente probados en el proceso, con el oficio N° 1-48-236-0126 del 14 de febrero de 2012, visible a folios 393 a 447 del c. o. suscrito por el Jefe de Gestión Jurídica Aduanera, el cual, a petición del funcionario instructor del proceso, realizó un informe comparativo de las cargas laborales. Con este documento idóneo, contentivo del cuadro de personal, funciones y carga laboral de la División aduanera, encontró acertadamente el fallador a quo que los 81 expedientes asignados a la procesada, resultaban ser una carga laboral menor, en comparación a las cargas asignadas a sus compañeros de labores, situación que en su concepto, no justificó su actuar descuidado.

Tampoco son de recibo las críticas que la misma procesada recurrente formula contra la compulsación de copias, con fines fiscales, ordenada por el fallador de instancia. Al respecto, se le recuerda a la servidora implicada que la procedibilidad o no de la acción Fiscal será evaluada en su momento por el funcionario competente de la Contraloría, motivo suficiente para confirmar esa decisión.

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-01-2012-89.

En lo atinente a las pruebas que reiterativamente pretende solicitar la procesada, dentro de sus alegaciones de segunda instancia, debe afirmar este despacho que las mismas no tienen ninguna prosperidad o procedibilidad, pues tal como lo manifestó el fallador a quo, acertadamente, dentro del presente juicio verbal disciplinario, el término probatorio feneció, resultando extemporánea e improcedente su petición.

Hechas las anteriores consideraciones, resta emitir un pronunciamiento sobre la petición de nulidad que en forma poco técnica presentó la defensa de la procesada, en uno de los puntos de su correspondiente escrito sustentatorio de la impugnación.

Sobre el particular, requirió el abogado defensor a esta instancia, la declaratoria de nulidad, con fundamento en las causales previstas en los numerales 2 y 3 de la Ley 734 de 2002. Como sustento de su pretensión, señaló que el funcionario de primer grado fracturó la estructura del proceso verbal, al resolver desfavorablemente una solicitud de prescripción de la acción, impetrada por la misma defensa, procediendo inmediatamente a correr traslado para alegar de conclusión, cuando en su concepto debió ordenar la continuación de la audiencia, bajo la secuencia establecida en el artículo 177 del C. D. U., modificado por el artículo 58 de la LEY 1474 de 2011. Adicionalmente, expresó el libelista que en el momento de reanudarse la audiencia, su prohijada presentó una solicitud de pruebas, sobre la cual no existió pronunciamiento favorable o desfavorable por parte del director de la audiencia.

Revisada la actuación, observa el despacho que no le asiste razón al profesional a cargo de la defensa técnica, cuando aduce una posible violación del derecho de defensa de la investigada, y mucho menos cuando afirma la posible existencia de irregularidades que, en su concepto, afectaron el debido proceso.

Veamos por qué:

Debe tenerse en cuenta inicialmente que el auto de citación a audiencia de la procesada debió ser notificado a la misma por edicto, ante la imposibilidad de realizarse una notificación personal, pese a las citaciones que le fueron realizadas. Llegado el 14 de noviembre del año 2013, se dio inicio a la audiencia, siempre con la presencia de los sujetos procesales. En el momento de darle a conocer a la investigada sus facultades y derechos procesales, señalados en los arts. 90 y 91 del C. D.U., la misma expresó su intención de otorgarle poder especial al abogado Pérez Cubillos para ejercer su defensa. Por lo anterior, inmediatamente se reconoció personería para actuar al citado togado, con quien se continuó el procedimiento. Al concedérsele el uso de la palabra interrogándolo sobre la posibilidad de solicitar nulidades procesales y pruebas dentro de la audiencia, el profesional del derecho únicamente reclamó la terminación y archivo del proceso, argumentando como razón la prescripción de la acción disciplinaria. En este mismo momento el abogado defensor expresó no presentar ningún alegato adicional, por considerar prescrita la acción disciplinaria.

Después de un receso decretado por el director de la audiencia, la misma continuó el 20 de noviembre de 2013, oportunidad en la cual la primera actuación del despacho a quo fue resolver negativa o desfavorablemente la petición de prescripción invocada por la defensa. A continuación, teniéndose en cuenta la inexistencia de solicitudes de nulidad o solicitudes de pruebas por parte de los sujetos procesales, el despacho declaró el cierre de la etapa probatoria del juicio, en el entendido de que tampoco había pruebas por practicar oficiosamente. Por esta razón, la actuación subsiguiente fue la de correr traslado para alegar de conclusión, ante lo cual, el defensor de confianza reclamó la ampliación de versión de su prohijada, solicitud que fue atendida favorablemente por la dirección de la audiencia, pese

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-01-2012-89.

a lo cual en esta misma sesión se recibió escrito de alegaciones finales o de conclusión por parte del abogado defensor.

Efectivamente, en sesión posterior de la audiencia, celebrada el 2 de diciembre de 2013, la vista pública se inició con la ampliación de versión de la procesada, quien presentó algunas pruebas documentales, las cuales fueron admitidas por el despacho a quo, para ser valoradas al momento del fallo. Igualmente reclamó la acusada, la práctica de algunas pruebas testimoniales, las que fueron rechazadas por el operador de instancia, por ser extemporáneas, al encontrarse la audiencia ad portas de realizar la correspondiente lectura del fallo de primera instancia, habiéndose incluso cumplido el término de alegaciones finales o de conclusión.

El anterior recuento procesal de la audiencia, permite a este despacho afirmar que el director del proceso, en la primera instancia, cumplió en su totalidad con las ritualidades propias del procedimiento verbal, las cuales se cumplieron siempre con la anuencia y presencia de los sujetos procesales, quienes voluntariamente expresaron en su momento o su intención de no solicitar pruebas y/o nulidades procesales.

Tampoco puede aceptarse la afirmación que en forma temeraria realizó la defensa, en el sentido de aseverar que la final petición de pruebas de la procesada, permaneció sin pronunciamiento del despacho a quo. Como quedó plasmado en los antecedentes procesales, hubo admisión de las pruebas documentales y rechazo simultaneo de los testimonios solicitados, por ser considerados extemporáneos, por el funcionario de instancia. Esta decisión, que dicho sea de paso se comparte en su integridad por este despacho ad quem, fue notificada en estrados a los sujetos procesales intervinientes dentro de la vista pública.

Basten las anteriores líneas, para rechazar, tal como se hará en la parte resolutive subsiguiente, las razones de nulidad de la actuación, invocadas por la defensa técnica en el presente proceso.

Las consideraciones hasta el momento realizadas permiten a este despacho rechazar los argumentos de impugnación de los sujetos procesales apelantes, para ordenar, consecuentemente, la confirmación integral del fallo objeto de alzada.

En tal virtud, la Directora de la UAE Agencia del Inspector general de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

PRIMERO. RECHAZAR las razones de **NULIDAD** alegadas por el abogado defensor (XXX), de conformidad con los razonamientos expuestos en la parte final de los anteriores considerandos.

SEGUNDO. RECHAZAR las razones de **IMPUGNACIÓN** presentadas por los sujetos procesales, (XXX), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

TERCERO. Como consecuencia de las anteriores determinaciones, **CONFIRMAR TOTALMENTE** el fallo sancionatorio proferido en audiencia, del 2 de diciembre de 2013, por el Subdirector Técnico de Investigaciones Disciplinarias de La Unidad Administrativa Especial Agencia ITRC, a través del cual se sancionó con **SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO**

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-01-2012-89.

DEL CARGO, POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES e INHABILIDAD ESPECIAL POR EL MISMO TÉRMINO, a la servidora (XXX), de condiciones civiles y personales conocidas en autos, por encontrarla responsable de incurrir en la falta disciplinaria, cometida en las circunstancias de modo, tiempo y lugar allí mismo referidas.

CUARTO. NOTIFICAR el contenido de esta decisión a los sujetos procesales, de conformidad con las previsiones legales contenidas en los artículos 101,104 y 107 de la Ley 734 de 2002.

QUINTO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

SEXTO. La presente decisión queda en firme el día de su suscripción, pero sus efectos jurídicos se surten a partir de la notificación, tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 119 de la Ley 734 de 2002.

SÉPTIMO. Una vez surtida la notificación del presente fallo, **REGISTRAR** La sanción disciplinaria ante la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, según lo ordena el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, en armonía con el artículo 48, numeral 57 de la misma norma. Igualmente **REMITIR** copia de la presente decisión al Director General de la DIAN para que proceda, en su calidad de nominador, a ejecutar la sanción impuesta, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º y PARÁGRAFO del artículo 172 del C. D. U.

OCTAVO. Ejecutoriada materialmente esta decisión y libradas las comunicaciones de ley, devuélvase el expediente al despacho de origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE
Directora General

Proyectó: Demetrio Augusto Parra Jiménez
Revisó: Demetrio Augusto Parra Jiménez
Aprobó: Carmen Maritza González M. – Directora General.